

1115913-38.2022.8.26.0100

Classe: Monitória

Assunto: Contratos Bancários

Magistrado: FLAVIA POYARES MIRANDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 28ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Furto de celular - Posteriores transações bancárias não reconhecidas pela correntista requerente - Responsabilidade da instituição financeira em garantir a segurança nos sistemas informatizados disponibilizados aos consumidores - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço (Art. 14, CDC) - Operações que destoam do perfil de consumo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

28ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1115913-38.2022.8.26.0100 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1115913-38.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Monitória - Contratos Bancários

Requerente:

BANCO SAFRA S/A

Requerido:

Barbara Tamiris Ferreira de Jesus-me e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA

Vistos.

BANCO SAFRA S/A, ajuizou ação monitória contra BARBARA TAMIRIS FERREIRA DE JESUS-ME (Nome Fantasia MIX ACESSORIOS) e BARBARA TAMIRIS JESUS DE MACEDO, alegando, em síntese, que dela é credora da quantia de R\$ 89.887,27, representada por "Proposta de Abertura de Conta Corrente e Contratação de Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica" descritas na inicial. Requereu a procedência da ação monitória, com a constituição do respectivo título executivo.

A inicial foi acompanhada de documentos.

A requerida foi citada e apresentou embargos à monitória a fls.107/113. Destaca preliminar de litispendência. No caso em tela a embargante ingressou com a ação de nº1008007-86.2021.8.26.0564, tendo em vista que foi vítima de falha na prestação de serviço do Banco Safra S/A, para ressarcimento do referido débito com a embargada, tendo inclusive obtido êxito tanto em primeira quanto em segunda instância de forma unânime. Aponta repetição da ação nº 1008007-86.2021.8.26.0564, cujas partes, pedido e causa de pedir são as mesmas. No mérito, alega, em suma, ausência de título hábil a aparelhar ação monitória. Pugna pelo acolhimento dos embargos.

Impugnação do embargado a fls. 395/404.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de embargos à ação monitória fundada em proposta de abertura de conta corrente pessoa jurídica.

Analisando-se a inicial e documentos, verifico as duas lides tratam da mesma conta bancária, e nº 5823549, cadastrada na agência nº 01100 do banco requerente, sendo que na ação ajuizada junto à E. 3ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo a requerida logrou comprovar em primeira e segunda instâncias que as transferências que resultaram na utilização do cheque especial e endividamento junto ao exequente foram oriundas de operações fraudulentas após assalto.

Enquanto isso, o banco instaurou a presente ação monitória precisamente para cobrar da requerida os valores em aberto na referida conta corrente, em decorrência da utilização do cheque especial.

Cumprir destacar, ainda, que no extrato juntado pelo requerente, em fl. 81, para basear a sua pretensão nesta ação monitória, constam diversos pix que motivaram a ação de nº 1008007-86.2021.8.26.0564, conforme se nota dos documentos de fls. 130, 162 e 165.

Assim, o banco requerente está cobrando, ao menos em parte, débito cuja exigibilidade foi e ainda está sendo discutida naqueles autos.

Não há que se falar em litispendência, tendo em vista que na ação proposta perante a E. 3ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo abrange período de tempo menor que o discutido nestes autos, cujos débitos datam de julho de 2021 ao momento presente.

Contudo, verifica-se que em ambas as ações executivas se analisa a exigibilidade dos valores utilizados na mesma conta corrente de exigibilidade controversa, posto que em discussão judicial.

Trago à colação v. Aresto proferido:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Furto de celular - Posteriores transações bancárias não reconhecidas pela correntista requerente - Responsabilidade da instituição financeira em garantir a segurança nos sistemas informatizados disponibilizados aos consumidores - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço (Art. 14, CDC) - Operações que destoam do perfil de consumo da correntista - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Responsabilidade civil objetiva do réu não afastada - Incidência da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Necessidade de ressarcimento das quantias indevidamente transferidas - Hipótese dos autos que revela ter a autora suportado prejuízos extrapatrimoniais que desbordam dos meros aborrecimentos não indenizáveis - Danos morais configurados - Precedentes desta C. 14ª Câmara de Direito Privado - Impugnações do banco requerido que não prosperam - Manutenção da r. sentença de parcial procedência que se impõe - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008007-86.2021.8.26.0564; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022)"

Feitas estas considerações, os embargos são procedentes.

Se não, vejamos.

Pelo que se afere dos documentos acostados aos autos, verifica-se inexistir prova da efetiva utilização dos valores por parte da requerida, o que retira do título a possibilidade de instruir ação monitória, sem prejuízo da possibilidade da ação de cobrança com ampla instrução probatória e discussão.

Comentando o assunto, Marcelo Brandão Fontana com muita clareza expõe:

"Nesta toada, é prova escrita para fins de demanda monitória a nota ou missiva confeccionada e encaminhada pelo devedor ao credor apenas ratificando esta sua condição, mas sem especificar valores, ou uma proposta de parcelamento da dívida; o orçamento do dentista assinado pelo paciente; a carta do cliente dirigida ao advogado anuindo a questão de honorários, forma de pagamento; dentre vários outros exemplos.

A melhor doutrina escreve que o procedimento monitório, "é o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não

apresentação de embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de obrigação de pagamento em dinheiro, entrega de coisa ou determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados".

É do mesmo escólio da lição de Marcato, citado por Theodoro Junior, "deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse utilizado no processo de cognição plena. Em síntese - e aqui lançamos mão de entendimento jurisprudencial já consolidado da Itália -, qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade". Mas, para melhor entendermos o alcance da expressão prova escrita, é imprescindível que esta seja analisada sob a ótica da posição do devedor e o juízo de admissibilidade.

3.2. A prova escrita não precisa ser emanada pelo devedor. A possibilidade de o credor ajuizar a ação com base em vários documentos.

É importante destacarmos a irrelevância de o documento estar subscrito ou não pelo devedor. Primeiro, porque a lei não exigiu. Segundo, o mais importante, o autor pode anexar vários outros documentos que, somados, são capazes de formar o convencimento do magistrado acerca do direito invocado, uma vez que a prova produzida na fase sumária é somente aquela que seja capaz de formar um mero juízo de probabilidade. Aliás, o credor poderá lançar mão de documentos produzidos unilateralmente que, somados a outros elementos, tenham força suficiente para formar a convicção do juiz e, conseqüentemente, um conjunto idôneo e apto.

É novamente de Marcato a lição de que:

é deferida ao autor a possibilidade de instruir sua petição inicial com dois ou mais documentos, sempre que a insuficiência de um possa ser suprida por outro (isto é, em seu conjunto a prova documental tenha aptidão para induzir a formação do convencimento do juiz), ou de valer-se de documento proveniente de terceiro, desde que ele tenha aptidão para, isoladamente ou em conjunto com outro, demonstrar a existência de uma relação jurídica material que envolve autor e réu, ai e, ainda, para atestar a exigibilidade e a liquidez da prestação.

(...)

O conceito de prova escrita, também, deve ser encarado sob a ótica do juízo de admissibilidade da demanda monitória, porquanto basta apenas a prova que permita ao juiz chegar a um juízo de probabilidade, não sendo necessária uma prova que demonstre o fato constitutivo.

Marinoni, mais uma vez, nos dá a lição de que:

Contudo, para que a doutrina possa se desincumbir desta tarefa adequadamente é imprescindível que ela esteja atenta para a razão pela qual exige-se a prova escrita. É preciso que fique claro o motivo que levou o legislador a condicionar o uso da ação monitória à presença de prova escrita, demonstrando-se que "prova escrita" não é sinônimo de "prova que pode demonstrar o fato constitutivo do direito, até porque o procedimento monitório não pode ser confundido com um procedimento verdadeiramente documental, como é aquele em que se veda a produção de prova diferente da documental (mandado de segurança)".

Nessa perspectiva, é importante frisar, portanto, que não é o critério da "certeza" que deve buscar o julgador quando da análise primeira da demanda monitória. O documento, a prova escrita que deve juntar o credor ao pedido é aquele que possa garantir ao magistrado firmar um juízo de admissibilidade do direito invocado por aquele, nada mais. Não há uma análise profunda do direito do autor, posto que, do contrário, geraria um formalismo excessivo. Se se fosse exigir do credor demonstrar um direito líquido e certo, não haveria razão para dar-lhe oportunidade de, nos embargos, produzir prova. O direito de defesa concedido ao credor e ao devedor é amplo.

O juiz, ao apreciar o juízo de admissibilidade de uma demanda monitória, verificará se a prova trazida pelo credor é apta para procedimento monitório, ou seja, se ela perpassa pelo crivo da probabilidade, sem que haja necessidade de imergir na questão da prova. A partir de então, qualquer tipo de matéria deve ser levantada e

discutida nos embargos , fato que nenhum prejuízo, frise-se, causa ao devedor, porquanto a apresentação dos embargos independem da segurança do juízo.
(...)

O procedimento monitório, desta forma, faculta ao devedor os mesmos meios de defesa do rito ordinário. Vale dizer, é concedida ao devedor a ampla defesa, surgindo daí a cognição exauriente. Não há razão, portanto, para se pensar que prova escrita seja absoluta e inquestionável. A própria posição geográfica em que se situa a demanda monitória - entre a execução e ação ordinária -, permite chegar-se à conclusão de que a prova pretendida é, sem dúvida, de menor complexidade e formalidade. Já que o procedimento monitório se situa entre o processo executivo e o ordinário, a questão da "prova escrita", exigida no artigo 1.102a do estatuto processual brasileiro, também aí deveria ser tratada. O credor de determinada soma em dinheiro, por exemplo, para valer-se da tutela monitória, deve possuir prova escrita que não lhe abra as portas da via executiva, como também não seja tão exaustiva como aquela exigida pela via ordinária. A prova escrita deve retratar, a princípio, um juízo de probabilidade para o magistrado".

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os embargos opostos e, em consequência, julgar improcedente a ação monitória, extinguindo-a com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com amparo no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa da ação monitória.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA